

势、表情等来实现与音乐作品《××A》所含思想情感相对应的情感表达，虽然具体的细节动作、姿势、表情等元素可能属于公有领域的内容或未证明其独创性，但各个动作、姿势、表情等元素的选择、编排所形成的组合，并无证据证明存在在先权利或亦属公有领域，故该等选择、编排具有独创性，由此形成在视觉上一系列动作、姿态、表情等元素的组合所成的动态整体，足以构成舞蹈作品。

二、舞蹈作品表达元素的范围

《中华人民共和国著作权法实施条例》对舞蹈作品的定义中，明确列举的舞蹈作品的表达元素包括动作、姿势、表情，但同时也以开放式的用语“等”，为划定舞蹈作品元素的保护范围留下弹性的司法认定空间。从日常生活经验看，一段舞蹈中，除了动作、姿态、表情作为常见的基本元素外，还经常性地会包含多种其他元素。通常而言，舞蹈多与配乐结合，舞蹈动作、姿势、表情与音乐节奏、旋律、演唱的歌词内容相呼应，共同用以表达一定的思想情感。但为实现或强化表达的效果，往往还会对与舞蹈动作、姿势、表情等相关的妆容、服装、道具以及舞蹈所在的舞台场景加以特别的设计和安排。需要指出的是，若舞蹈所含的一系列动作、姿势、表情等因素，以及与之有关的不可缺少的妆容、服装、道具及舞蹈的舞台场景，整体上可以实现对某一思想情感的独创表达，则舞蹈作品不仅是该一系列连续的动作、姿势、表情等元素之结合，还应包含为实现或强化舞蹈表达的舞台艺术元素。

具体而言，舞蹈作品的艺术效果不能单独割裂只看动作本身，服装、化妆、道具等舞台艺术对于舞蹈作品效果的呈现也具有重要的影响。因为舞蹈作为一种舞台艺术表现形式，需要在统一的艺术构思的基础上，将舞蹈动作与光影、服装、音效、演员装扮等舞台艺术有机结合，共同呈现完美的艺术效果。如表演传统秧歌的服饰较为固定，一般为红色、绿色的北方服饰，若舞者穿着秧歌服饰表演迈克尔·杰克逊的经典舞蹈太空步，虽动作一致，但所呈现的效果必将大相径庭。妆容也是一样的道理，不同妆容

影响舞者的舞台表演效果，该影响可以参考同为舞台艺术的戏剧。我国传统戏剧中将演员行当分为生旦净末

丑五个类别，不同类别的演员妆容不同，最为明显的是演员脸谱颜色和样式不同。如京剧脸谱中红色的脸谱表示人物忠勇义烈，黑色的脸谱表示刚烈、正直、勇猛甚至鲁莽，黄色的脸谱表示凶狠残暴，蓝色或绿色的脸谱表示一些粗豪暴躁的人物，白色的脸谱一般表示奸臣、坏人。若演员的妆容扮错，整个作品的表现效果必将大打折扣。因此，若舞蹈动作、姿势、表情等与舞台背景、光效、音乐、道具等共同结合，形成舞蹈作品不可分割的整体表达，则亦应属于舞蹈作品的保护范围。

本案中，北京某娱乐公司的舞蹈以整体呈现为暗黑色舞台背景加蓝色光效为表演场景，包含一系列由领舞单独或与伴舞共同完成的连贯性身体动作、机械化的姿势或茫然或癫狂的表情、类似小丑妆的妆容等元素，领舞、伴舞的部分动作利用舞台沙发道具实现。此外，涉案《××A》舞蹈系用于与音乐作品《××A》配套表演，根据介绍该音乐作品含有人声低吟、尖叫、古老的歌剧等元素，形成一丝恐怖气氛，具有一种暗黑风格。上述舞蹈作品内容通过与《××A》音乐旋律、节奏及歌词内容相呼应而进行独创性编排，由此组合形成具有一定艺术美感的视觉整体，可以与《××A》音乐作品的情感表达主题相契合，共同实现该舞蹈的独创性，故该等元素均属于涉案舞蹈作品的要素。

三、整体观感法加关键元素比对法的应用

司法实践中，对侵权作品的认定遵循“接触+实质性相似”的判断公式，若被控侵权人曾接触过原告作品，同时被控侵权作品又与原告作品存在内容上的实质性相似，除非有合理使用等法定抗辩事由，否则即可认定为侵权作品。^①从该原理出发，法院判断作品实质性相似的比对一般采用“整体观感法”（整体对比法）和“抽象分离法”（部分比较法）。所谓“整体观感法”，是指以普通观察者对作品整体上的内在感受来确定两部作品之间是否构成实质性相似；“抽象分离法”是指通过抽象的手段，将作品中的思想、事实或通用元素等不受保护部分予以分离，以作品中受保护的部分进行比对，从而判定两部作品是

①王迁：《知识产权法教程(第七版)》，中国人民大学出版社2021年版，第78页。

否构成实质性相似。^①

不同作品类型的表现形式与受众的感知方式不同，故侵权比对的方法也应有不同，鉴于舞蹈作品的表现方式及其特点，故选取整体对比法进行实质性相似对比的方法更为科学。一是舞蹈作品通常是一段连续的动作、姿势等元素编排成的整体，具有高度的视觉化表现形式，其呈现方式就是观众直接的观看效果，并非阅读文字作品时需要在脑海中将文本文字进行到思想感情的转化，不涉及思想与表达的抽象与分立，对比时仅需将舞蹈的视觉效果进行比较即可。二是限于舞蹈作品篇幅原因，不一定需要传递出情节，无法进行抽象与分立对比。不可否认部分舞蹈作品具有一定的情节。但对于篇幅较小的舞蹈作品，其表达体量不够，无法充分展示动作背后的情节。故选取整体对比法进行舞蹈作品的实质性相似对比更为适宜。

整体对比法的具体适用过程中，除非原被告舞蹈完全一致认定必然侵权，否则就需综合分析两者舞蹈的相同与不同之处，此时需要着重将舞蹈作品中如关键舞蹈动作的关键元素作为比对分析的重要参考要点。一方面关键元素对观众的视觉感知、调动情绪和舞蹈表演的推动发挥重要作用，比如关键舞蹈动作往往在舞蹈整体中较之其他舞蹈动作更具视觉冲击力。另一方面关键元素的选择使用及在舞蹈编排中的地位，凝聚着舞蹈作品作者极高的独创性，某些舞蹈关键动作甚至可能成为整个舞蹈动作中的标志性动作，为观众所知悉。所以在侵权比对若有多个关键元素的一致或实质性相似，从观众角度出发，容易产生两个舞蹈整体一致或近似的判断。

本案中，基于原告的涉案舞蹈作品在先公开进行了传播，可以认定被告接触了原告作品，故涉案作品的实质性相似比对就是本案的审理重点。^②

从原、被告舞蹈的设计细节进行对比，两者确实存在一些区别：如原告

^①梁志文：《版权法上实质性相似的判断》，载《法学家》2015年第6期。

^②为进行全面和整体对比，本案判决书附件将原被告舞蹈进行了舞台及道具、舞蹈结构和动作、姿势、表情等三大部分的拆分，并对动作细分，逐一描述动作过程和舞蹈作品的元素，并进行详细对比。

舞蹈是一人领舞加两人伴舞，被告艺人的舞蹈则是一人领舞加一人伴舞，两个舞蹈的部分具体的动作姿态等细节上也有一些不同之处。但两个舞蹈的相同或实质性相似部分占据主要内容，如被告所用舞台与原告舞台均呈偏暗黑色背景加蓝色光效，均有舞蹈相关的沙发道具，均为单人舞开场、中段为领舞加伴舞、单人舞收尾的三段编排结构。在三段舞蹈表演进程上，无论是领舞的独舞还是领舞与伴舞的组合舞蹈，部分动作的展开方式、动作之间的衔接、领舞与伴舞的互动动作模式，具有较高的相似度，比如均有领舞弯腰并用左手半遮眼、领舞及伴舞双掌相互交叉作翅膀状、伴舞在地板上翻滚一周后坐地板上双手拍双膝。在表达情感细节的关键动作上，均有领舞作发狂状、伴舞对领舞作“微抱”“虚摸”状、第三段舞蹈过程中均有类似拉长嘴角(原告的舞蹈为拉长口红)至脸颊部位形成类似小丑妆的妆容等，这些细节要素比较容易在观众视觉上留存更深印象或视觉冲击力。虽然三段舞蹈表演中，部分舞蹈动作、舞者表情姿态，以及伴舞的数量、道具沙发的颜色等细节存在差异，但基于整体的舞蹈背景氛围、道具与舞者的关系、舞蹈的节奏和编排段落、舞蹈各段落的关系和推进进程方式、关键舞蹈动作和妆容细节、领舞与伴舞的互动关系及互动方式等方面存在较高的相似性，从整体上，被诉舞蹈与原告的舞蹈作品，构成实质性相似。

尽管上海某文化公司表演的涉案舞蹈与北京某娱乐公司的权利舞蹈部分细节存在不同之处，但从整体上看，尚没有形成独立于原作的新作品，故并非侵害北京某娱乐公司对权利舞蹈享有的改编权。综上，法院判决认定上海某文化公司未经许可向公众表演北京某娱乐公司舞蹈，侵害北京某娱乐公司享有的表演权，将表演的舞蹈录制后上传到信息网络供公众观看侵害了北京某娱乐公司的信息网络传播权。

编写人：上海市杨浦区人民法院 张呈 苏亚博

工业产品外观之著作权、专利权叠加保护 成因及其权利边界厘定

——上海某材料公司诉广州某墙纸公司著作权侵权案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广州知识产权法院(2021)粤73民终4810号民事判决书

2. 案由：著作权侵权纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):上海某材料公司

被告(被上诉人):广州某墙纸公司

【基本案情】

上海某材料公司于2018年9月7日向国家版权局申请登记名称分别为“C××”及“B××”的美术作品,并获颁发《作品登记证书》。材料公司称其为开发适用于酒店、商业空间及高端家装的背景墙面,创作涉案“C××”及“B××”设计,两款墙纸有强烈的艺术感和时尚感,构成著作权法保护的极简主义美术作品,“C××”作品自砖墙里获得了灵感,将长方形做凹凸处理,并增加线条,使立体感突出;“B××”作品从石块状的建筑外墙和织物获得灵感,将宽度不等的长方形状的立体图案随机组合,用细腻布纹增加画面柔和度。上海某材料公司主张广州某墙纸公司生产、销售的两款被诉墙纸与“C××”“B××”墙纸近似度高,侵犯其对“C××”“B××”两款墙纸的复制权及发行权。

“V××”微信公众号于2016年5月3日、2016年10月24日发布的文章中

称“V×× 总部在2016年春季向全球推出了全新的七种墙布系列产品”，并分别展示“C××”“B××”墙纸。

广州某墙纸公司提交的专利号为ZL2012××.4。 名称为“墙纸(74)”的外观设计专利文献显示，该专利为方形墙砖凹凸相接的墙纸产品设计，该专利的申请日为2012年6月27日，授权公告日为2012年10月10日。

【案件焦点】

1. 工业产品外观能否以极简主义美术作品标准获得专利权、著作权的叠加保护；2. 工业产品外观的著作权、专利权之间的边界及权利认定标准。

【法院裁判要旨】

广东省广州市越秀区人民法院经审理认为：“C××” 墙纸由大小一致的、凹凸不平的小长方形组成；“B××” 墙纸由大小不一的、宽度不等的、厚度相同的类似石块的立体图案组成。上述墙纸图案的色彩单调，组成元素为一般公众所熟知的图形，色彩和图形的整体构图亦属于简单搭配组合，并未展现出独立于其实用功能的艺术成分，未达到作为美术作品应有的创作高度及审美意义，涉案墙纸未构成美术作品。

广东省广州市越秀区人民法院依照《中华人民共和国著作权法》第三条第四项，《中华人民共和国著作权法实施条例》第二条、第四条第八项，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：

驳回上海某材料公司的全部诉讼请求。

上海某材料公司不服一审判决，提起上诉。

广州知识产权法院经审理认为：《中华人民共和国著作权法》所列举的作品种类未包括实用艺术作品，对于受著作权法保护的实用艺术作品的认定，应结合《中华人民共和国著作权法实施条例》第二条、第四条对美术作品标准进行判定。虽实用艺术作品兼具实用性和艺术性的双重属性，但实用艺术作品在寻求获得著作权保护时，对其独创性的判断标准应着重于艺术性。达到一定的艺术创作高度，足以体现作者在美术领域的独特创作。

当工业产品作为实用艺术作品寻求著作权保护时，由于著作权保护期限长、缺乏法定授权确权程序、无效宣告程序及相应的失权公示程序，如工业产品的著作权保护标准设定过低，容易导致经营者转向谋求工业产品外观的著作权保护，更容易导致外观设计专利审查制度被架空和著作权的滥用，故在认定工业产品是否因具有审美意义的独创性而受到著作权保护时，据以判定审美意义独创性的艺术创作标准应略高于外观设计专利产品的新颖性标准。本案中，墙纸产品获得著作权保护的前提是其设计具有著作权法上审美意义的独创性。涉案“C××”“B××”墙纸设计早已公开宣传、销售，难以依据专利法获得外观设计专利权的授权。而且，相对于在先的外观设计专利设计而言，前述二者设计的独创性未达到略高于外观设计专利的新颖性标准，也未达到著作权法上审美意义的独创性。上海某材料公司主张广州某墙纸公司侵害著作权的意见依据不足。

综上所述，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，法院予以维持。上海某材料公司的上诉请求不能成立，法院不予支持。

广州知识产权法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项的规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

随着商品市场的多元化，越来越多的工业产品经营者意图通过著作权诉讼来获取对其产品外观设计的排他性保护。尤其是，部分案件中，经营者主张其工业产品外观构成极简主义美术作品，实践中，如工业产品外观的可版权性认定标准过低，容易导致工业产品外观谋求著作权与专利权的叠加保护，更容易导致外观设计专利审查制度被架空和著作权的滥用，不仅违背专利保护制度的法旨，也不利于工业创新发展。现代商业模式下，如何有效规制因工业产品外观的著作权认定标准过低而导致外观专利审查制度架空、著作权滥用，并实现对文化创作的严格保护，成为司法实践中的难点和热点问题。

一、关于实用艺术作品的独创性标准与外观设计专利产品的新颖性标准、商品特有装潢的识别性标准之间的关系

上海某材料公司主张其涉案“C××”及“B××”墙纸设计为极简主义美术作品。在司法实践中，经营者在工业产品外观难以获得外观设计专利权的情况下，通过提起侵害著作权诉讼或不正当竞争之诉来获取对其产品外观设计的排他使用权益。但是，工业产品外观的专利权、著作权及知名商品特有装潢权益之间的法益并不相同，其受法律保护的程度并不相同，其获得权利的标准也应有所区别。

(一)关于外观设计专利权、著作权、商品特有装潢权益的保护对象之重合

依据《中华人民共和国专利法》第二条第四款规定，外观设计专利保护的客体为产品的形状、图案及色彩相结合的美感设计。依据《中华人民共和国著作权法》第三条及《中华人民共和国著作权法实施条例》第二条、第四条规定，实用艺术作品是指以线条、色彩或者其他方式构成的有审美意义的平面或者立体的造型艺术作品。依据《中华人民共和国反不正当竞争法》第六条的规定，在商品外部所附的图案及其排列组合所构成的装潢，当其能够区别商品来源时，即属于《中华人民共和国反不正当竞争法》保护的装潢。由此可见，就工业产品而言，产品装潢、产品外观设计和实用艺术作品同样是基于其外部形状、图案、色彩或者三者的结合所形成富有美感的产品设计。因此，外观设计专利权、著作权、特有装潢权益在保护工业产品外观设计时，三者的客体存在重合性。相对而言，实用艺术作品在类型上更接近外观设计专利产品。在判定实用艺术作品是否达到具有审美意义的独创性问题上，外观专利设计产品的新颖性及可专利性判定标准具有一定的参考价值。

上海某材料公司在本案中主张墙纸著作权实质是对作为立体工业产品的墙纸外观设计主张以著作权进行保护。实用艺术作品兼具实用性和艺术性的双重属性，但对其独创性的判断应注重于艺术性，实用艺术作品应具有审美意义，达到一定的艺术创作高度，可表现作者在美术领域的独特创作和思想。

(二)关于工业产品的外观设计专利权、著作权、特有装潢权益认定标准之差异

1. 从有效保护期来看，实用艺术作品的著作权保护期，远长于外观设计专利权的保护期^①。《中华人民共和国著作权法》第二十三条规定，著作权的财产权利保护期截止于作品首次发表后第五十年的12月31日，亦即，著作权的财产权利保护期不低于五十年。修订前的《中华人民共和国专利法》规定，外观设计专利权的期限为自申请日起计算十年，《中华人民共和国专利法》于2020年修正后，外观设计专利权的保护期为十五年。由此可见，实用艺术作品的著作权保护期超出外观设计专利保护期至少达三十五年之久。

2. 从授权审查程序及失权宣告程序来看，专利法对于外观设计专利的确权程序、失权程序及其法律后果均作出明确的法律规定。《中华人民共和国专利法》第四十五条中规定，任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的，可以请求国务院专利行政部门宣告该专利权无效。第四十六条第一款中规定，宣告专利权无效的决定，由国务院专利行政部门登记和公告。第四十七条第一款规定，宣告无效的专利权视为自始即不存在。由此可见，对于外观设计专利产品而言，外观设计专利的取得需经授权程序，且其可能因缺乏新颖性而被宣告无效，外观设计专利权被宣告无效后，有相应专利权失权的公示制度。此外，外观设计专利的授权保护范围仅限于指定的产品类别。而著作权、商品特有装潢并无法定的授权确权、失权程序，通常以提起侵权诉讼的形式进行确权，著作权的权益也不因使用与否的原因而导致减损。

二、关于工业产品外观获取著作权法、反不正当竞争法保护的前提条件

著作权法、专利权法、反不正当竞争法对于工业产品外观的保护是否叠加式的问题，存在较大争议。部分意见认为，三者的保护客体不同，边界清晰；部分观点认为，当工业产品的外观具备技术性、艺术性、识别性时，可获得叠

①在《保护文学和艺术作品伯尔尼公约》第二条第七款中，要求成员国保护实用艺术品和工业品外观设计，实用艺术品的保护期可以短于一般文学作品的保护期，但不得低于该作品完成后的25年。

加保护模式。

(一)著作权法、专利权法、反不正当竞争法保护的客体

上海某材料公司在本案中主张其“C××”及“B××”墙纸设计为极简主义美术作品。一项工业产品的外观,可能同时具备技术性、艺术性、识别性,但其获得著作权法、专利权法、反不正当竞争法上权益的基础并不相同,三者并非叠加关系。

1. 著作权法保护的是作品所体现的美感性、艺术性、独创性,是基于审美价值所体现出来的创造性智力投入。

2. 专利权法对于外观的设计方案予以保护,保护的是产品外观的新颖性和美感,以及与产品结合,其权利所保护的是图案和产品结合背后所体现的一种竞争优势。

3. 反不正当竞争法对于商品特有装潢的保护,是基于对商品特有装潢所承载的识别性和商誉,以及其所形成的市场资源配置及竞争秩序。

(二)著作权法、专利权法、反不正当竞争法对于工业产品外观保护标准的认定及其边界

无论能否成为极简主义美术作品,即使具备技术性、艺术性、识别性工业的产品外观,获得专利权法、反不正当竞争法对于工业产品外观的保护程度不同,其获得著作权法、专利权法、反不正当竞争法的标准亦应有所不同,三类法益之间并非叠加关系。

1. 如工业实用艺术作品在民事诉讼程序中获得著作权的确认,则其法律效果包括权利人对该工业设计的实用艺术作品享有不少于五十年的绝对权利。而且,在现行法律制度中,实用艺术作品的著作权确权并未设置相应的失权程序及失权公示程序,故即使在具体案件中该实用艺术作品被认定为非美术作品,也缺乏相应的登记程序对著作权失权的状态进行公示,该认定不必然导致作品登记撤销程序的启动。因此,相应地,实用艺术作品具有独创性的艺术美感部分所达到的艺术创作高度也应高于外观设计专利产品。

2. 工业产品的实用性与艺术性在理论上具有可分离性，但在判断标准上始

